

1517846-68.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... idade e já tive passagem pela Fundação Casa por tráfico e assalto.

Ocorre, porém, que as negativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem, ao acaso, reconhecidos pela vítima e acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem eles, efetiva participação nos fatos. Ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517846-68.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517846-68.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2147438/2021 - 47º Distrito Policial - Capão

Redondo, 4154/2021 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO GABRIEL JESUS DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 781/21

VISTOS.

ALEXANDRE DE LIMA MARQUES DA SILVA e CLÁUDIO GABRIEL JESUS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 158, § 1º e 3º, em concurso material, todos do Código Penal, porque consta que no dia 18 de maio de 2021, na Avenida Guido Caloi, 2221, Jd. São Luís, nesta capital, agindo em concurso com outro agente não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo HONDA/HR-V EX CVT, placa DKH3G41, o automóvel modelo HONDA/HR-V, placa DKH3G41, o celular da marca Apple, um tênis, documento de habilitação, cartões bancários, cartões de créditos, carteira do seu convênio de saúde, uma nécessaire com pertences de higiene e R\$ 62,00 em espécie em prejuízo da vítima D.d.S.S..

Consta, também, do incluso inquérito policial que, 18 de maio de 2021, na Avenida Guido Caloi, 2221, Jd. São Luís, nesta capital, ALEXANDRE DE LIMA MARQUES DA SILVA e CLÁUDIO GABRIEL JESUS DOS SANTOS, agindo em concurso com outro agente não

identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima D.d.S.S., a fim de obterem vantagem econômica indevida, através de transferências bancárias e gastos que ainda estão sendo apurados pela vítima.

A denúncia foi recebida, à fl. 77.

Resposta à acusação à fl. 105.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, uma testemunha de acusação, e os réus foram interrogados.

Convertidos os debates em memoriais, a representante do Ministério Público a fls. 127/144, , pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, a fls. 148/168, requereu a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento de crime único, afastamento das qualificadoras, reconhecimento da minoridade relativa, pena no mínimo e regime mais brando, com direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11 dando conta do veículo da vítima localizado e apreendido em poder dos réus, bem como pelo boletim de ocorrência de fls. 05/08, dando conta dos bens que os réus subtraíram e não foram recuperados.

Em complementação, temos os comprovantes das transferências efetuadas da conta da vítima para o réu Alexandre, às fls. 25/30, bem como fotografias de redes sociais e identificação do réu Claudio pelo Detecta, à fl. 31.

A autoria também é inconteste.

As negativas dos réus, secundadas pelos argumentos da Douta Defensoria Pública, não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas derivadas contra os réus, em especial pelas testemunhas inquiridas e declarações dos próprios inculpatos, que nada de exculpatório trouxeram aos autos.

Ouvido em Juízo, o réu CLAUDIO negou a acusação dizendo que eu estava em casa, na casa da minha mãe. Liguei para o Alexandre, porque a gente cresceu junto. O filho dele tinha nascido, eu queria conhecer. Ele disse que estava trabalhando, eu fui até a casa da mãe do filho dele, para conhecer. Assim que a gente chegou lá, ele chegou do trabalho. Ficamos lá, conversando, minha mãe foi embora, e eu fiquei lá com ele. Nisso, Jonathan ligou e perguntou se eu estava com Alexandre, eu disse que sim, ele pediu para falar com ele, eu passei o telefone para ele, que falou com Jonathan. Ele me disse que Jonathan e Mateus pediram uma conta dele para fazer o pagamento de uns motores de bicicleta, ia transferir o dinheiro para ele, e também outra conta para mandar outro dinheiro, mas não especificaram qual dinheiro era. Por volta da meia noite, Jonathan ligou de novo e convidou a gente para ir na casa dele, comer e beber. Nós fomos, lá estava o Mateus e Iago, ficamos lá comendo e bebendo. Tiramos fotos sim, comendo e fumando. Jonathan não chegou de carro, porque a gente estava na casa dele. Não cheguei a ver carro nenhum. Não conheço a vítima, não sei se é professor. Tenho 19 anos de idade e já tenho passagem pela Fundação Casa por roubo. Fui preso em flagrante, mas Alexandre não estava junto.

No mesmo sentido foram as declarações do réu ALEXANDRE, que em juízo Jonathan me ligou através do celular do Iago, estava ele o Mateus e perguntou se o Claudio estava comigo, que estava sim. Ele pediu meus dados bancários, que ia pagar o dinheiro de uma bicicleta que vendi para ele e o outro dinheiro ele ia pegar depois. Eram duas contas, uma no banco do brasil, que ele fez um pix no valor de 2500 reais e a outra conta também foi depositado. Nós fomos para casa do Iago, onde estava o Mateus, Mauricio e outras pessoas. Jonathan chegou com a chave do carro, o HRV, um celular, tênis e uma mochila com vários objetos. Eles estavam bebendo. Eles disseram que tinham acabado de cometer um BO. Eu perguntei desse dinheiro que foi depositado na minha conta, em nome da vítima Denilson, ele disse que era de um amigo dele. Nós fomos sacar esse dinheiro, minha conta estava bloqueada, dizendo que a vítima tinha contestado o depósito. Depois de três dias chegou uma intimação

para Claudio comparecer na delegacia. Eu fui preso em flagrante com o Claudio e neste roubo, eu estava mesmo. A vítima era meu professor, eu conhecia ele. Tenho 20 anos de idade e já tive passagem pela Fundação Casa por tráfico e assalto. Ocorre, porém, que as negativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem, ao acaso, reconhecidos pela vítima e acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem eles, efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existe um indício sequer a revelar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus ou mesmo acusa-los falsamente.

Além disso as contradições existentes nas declarações dos acusados fragilizam sobremaneira a possibilidade de ser dada quaisquer credibilidades a elas. Veja que enquanto Claudio afirmou que Jonathan não havia chegado com carro nenhum porque estavam na casa dele, Alexandre, contrariando a versão de seu comparsa, confirmou que Jonathan chegou ao local com as chaves de um veículo, eis que estavam na casa de Iago.

Desta feita, as provas dos autos falam por si e se encaixam como uma luva, não deixando dúvidas quanto a autoria delitativa, devidamente confirmada com relação a ambos acusados.

Tanto é que a vítima D.S.S., na fase inquisitiva, após reconhecimento fotográfico, reconheceu o réu Alexandre como um dos roubadores de seus bens, salientando que foi o indivíduo que o abordou no mictório portando uma pistola, fls. 15. Em juízo declarou que eu saí do meu serviço, passei na academia, sou hipertenso, não estava me sentido bem, e transitando para minha residência, parei o carro e fui no sanitário. Lá fui abordado pelo réu Alexandre, que segurou meu braço, anunciou que era um sequestro e que eu era o proprietário do veículo Honda HRV. Ele tirou meu celular e as chaves do carro, e me conduziu até meu carro, juntamente com o réu Claudio e um menor, o qual estava armado com uma pistola e sentou atrás comigo. O réu Claudio assumiu o volante do carro enquanto Alexandre ficou no banco do passageiro. Depois o réu Alexandre assumiu a direção do carro e foram até a região de Osasco, onde pararam e desceram do carro, a fim de passar meu cartão. Enquanto eu estava em poder deles eles exigiram a entrega do meu cartão e senha. Eles não conseguiram, voltaram e disseram que se não desse certo iam me matar. Então passaram a rodar comigo, e perguntaram onde eu morava, quando eu disse que na região de Interlagos. Eles pararam em frente a uma Adega, me deixaram no carro junto com o menor, os réus foram na adega, onde fizeram uma compra de aproximadamente 950 reais. No retorno, fizeram vários pix, um no banco bradesco no valor de mais de quatro mil reais, depois outro de 500, até que travou meu cartão. Eles fotografaram meus cartões do Bradesco e do Santander e enviaram para outras pessoas. Depois passaram meu cartão em outra adega, no valor de 1500 reais, fizeram o descarrego das bebidas que tinham comprado, e foram em direção a Avenida Guarapiranga, depois retornaram para Osasco, até que pararam em um a rua deserta e fizeram eu descer do carro. Eu caminhei até um posto e pedi ajuda. A polícia militar me levou até a delegacia de Embu das Artes, mas a autoridade policial não quis fazer o boletim de ocorrência, então eles me levaram até a delegacia de Itapeverica da Serra, dali eu fiz contato com meus familiares, que foram me buscar. O réu Alexandre deixou o documento dele cair no carro, foi quando eu vi o nome dele. Depois eu puxei o extrato do meu banco, quando apareceram os dados dele. Através das redes sociais eu consegui identificar tanto ele como o réu Claudio. Reconheci os dois réus nesta audiência. Permaneci em poder deles por mais de cinco horas. Eles levaram meu carro, meu celular, dinheiro, cartões. Tive um prejuízo de mais de dez mil reais em razão das compras e saques feitos nos bancos, os quais não me ressarciram de nada.

Atenta ao relato prestado pela vítima observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que

serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Ora, não se pode crer que o réu ALEXANDRE tenha sido especificamente reconhecido pela vítima como o sujeito que a abordara no banheiro público, tenha sido o destinatário da transferência PIX realizada e, ainda, esteja em uma fotografia com os objetos comprados no íterim dos crimes no dia dos fatos, não fosse ele efetivamente um dos agentes do assalto.

Veja que, da mesma forma, o réu CLÁUDIO foi reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima, a qual permaneceu por cerca de 5h em poder dos réus, ou seja, tempo mais que suficiente para memorização de suas características físicas.

Destarte, a despeito dos argumentos defensivos, temos que os reconhecimentos fotográficos feitos pela vítima na fase inquisitiva, foram devidamente confirmados pelos reconhecimentos pessoais ocorridos sob o crivo do contraditório. Não há que se falar em indução. E isso porque a vítima foi firme em descrever a conduta de cada agente, de forma clara, objetiva e detalhada. Tal circunstância por si só, já é mais do que suficiente a demonstrar que na ocasião, foram sim, os réus que praticaram os fatos que ora se apuram.

Além do mais, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítima e acusados, de modo que possa resultar em intenção de prejudicar os réus ou mesmo acusá-lo falsamente. Não é crível que a acusação se fundamente em vingança ou outro motivo qualquer, quando as partes são desconhecidas e não há sequer indícios de amizade ou inimizade entre elas.

Tanto é que o Delegado de Polícia, Diego Barbosa de Carvalho, declarou em juízo que eu tomei conhecimento do caso, por força de notícias da polícia militar. Eu trabalho no plantão, com uma equipe reduzida, de maneira que a PM nos ajuda bastante. Eu intimei a vítima, tomei as declarações dele, e obtive por meio de um comprovante de pix, que havia sido feita uma transferência em nome de Alexandre, quando obtivemos a fotografia dele, que foi reconhecido pela vítima. Passamos a monitorar as redes sociais dele, quando vimos uma foto dele com o réu Claudio e Jonathan, vulgo galego, em poder de várias bebidas alcoólicas, foto esta postada no mesmo dia dos fatos. Passamos então a tentar identificar esses dois agentes. A vítima identificou o réu Claudio, e o reconheceu também fotograficamente. Passados mais de um mês, eu estava de folga, a Força Tática entrou em contato, dizendo que os réus teriam sido presos em um crime, praticado com o mesmo modus operandi, da vítima Denilson. Fui até a delegacia acompanhar a prisão em flagrante deles. Havia um menor, de nome Iago, que estava usando o tênis da vítima Denilson. Foi então quando a vítima identificou que eram quatro agentes no momento dos fatos. Na oitiva deles, Alexandre disse que não participou, mas apenas orientava o grupo, fornecendo os dados bancários, porém a vítima relatou que ele conduzia o carro e no crime que ele foi preso ele também conduzia o veículo. Claudio negou o tempo todo, porém o réu Alexandre disse que Claudio estava nos fatos, em conluio com o menor Jonas. Reconheço os dois réus e não os conhecia anteriormente.

A autoridade policial também confirmou em Juízo o reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Assim como a vítima, a autoridade policial era estranha aos réus, não havendo motivo para que seu depoimento seja desprezado. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998:

"O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham

participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que os réus, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, inicialmente, subtraíram para eles, bens de propriedade da vítima.

Duas foram as condutas perpetradas pelos agentes, com dolos distintos. No tocante ao roubo, houve a subtração, com emprego de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, dos bens das vítimas.

Em um segundo momento, a intenção dos agentes, além da subtração dos bens, ainda com emprego de grave ameaça com emprego de arma de fogo, dirigiu-se a obter da vítima indevida vantagem econômica, consistente na entrega de senha de cartão bancário.

Assim, embora as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto fático, ensejam o reconhecimento de dois delitos diversos, quais sejam, o roubo e a extorsão, em concurso material. Ainda que se tratem de delitos de gênero material, são infrações que não possuem a mesma espécie jurídica, decorrentes de desígnios completamente autônomos.

Lecionando sobre o tema, o autor JULIO FABRINI MIRABETE, na obra CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, 7ª edição, editora ATLAS, ao comentar os artigos 157 e 158 do Código Penal, explica que: "Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada". (pg. 1089).

Também explica o tema o ilustre Guilherme de Souza Nucci: "A Lei 11.923/2009 criou a figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no art. 158, § 3º, do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão, bem como a previsão da possibilidade de dois resultados qualificadores (lesão grave e morte). No mesmo parágrafo, houve o aproveitamento para a inclusão de uma qualificadora (crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), com pena de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa, mas também trouxe a figura qualificada pelo resultado, ou seja, se do sequestro relâmpago advier lesão grave, a pena será de reclusão, de 16 a 24 anos; se ocorrer morte, a pena será de reclusão, de 24 a 30 anos. Em primeiro lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal ('se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade'). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3º o art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica (...)." (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, editora Forense, 15ª ed., pág. 917).

E não é apenas a doutrina que segue esse entendimento. Eis a jurisprudência de nossas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE

DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113900 SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.11.2014). "(...). Na hipótese vertente, verifica-se que o Paciente foi condenado como incurso nas sanções dos crimes de roubo e extorsão, sendo, pois, inaplicável a regra da continuidade delitiva. Embora os delitos de roubo e furto pertençam ao gênero dos crimes contra o patrimônio, não são da mesma espécie, razão pela qual não se configura hipótese de crime único ou continuidade delitiva, mas sim o concurso formal ou material. Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são

aqueles previstos no mesmo dispositivo legal, isto é, que possuem o mesmo tipo fundamental, abrangendo as formas simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas. (...). Ante o exposto, DENEGO a ordem" (STJ HC 162.862 SP, Rel. Min^a Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.05.2012).

Tal a hipótese dos autos. Os agentes, mantendo a vítima subjugada, subtraíram seus pertences, e ainda, constrangeram-na a fornecer senhas, de modo que incorreu nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material.

O fato das armas utilizadas pelos réus não terem sido apreendidas, nada abala sua procedência. Aliás, reiterada jurisprudência no sentido:

"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido. (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010)" "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Que os réus agiram em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas palavras da vítima firmes no sentido, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos. Veja que a vítima declarou que foi abordada por indivíduos armados.

Outrossim, o artigo 158, § 3º restou comprovado. Os agentes não se contentaram em apenas constranger a vítima, obtendo dela, mediante grave ameaça os cartões e respectivas senhas. Prolongando seu sofrimento, impingiram nela um temor cruel e desnecessário, eis que ingressaram com ela no veículo, mantendo-a como refém, tudo de forma absolutamente desnecessária.

Desta feita a hipótese é aquela prevista no artigo 158, §§ 1º e 3º do Código Penal. Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Os réus são primários, menores de 21 anos de idade, e não ostentam antecedentes criminais, assim, fixo suas penas base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa para o roubo e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para a extorsão qualificada.

Sobre a pena-base do roubo incidirão, ainda, as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 3/8 e alcançará 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Neste sentido: "Em matéria de causa de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento, 1/3, deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações nº 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1.034.383/1, 1.036.617/0).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo."

(Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, relator).

Na situação o aumento de 3/8 é o mais indicado, eis que ambos os réus, agindo juntos e com emprego de arma, abordaram a vítima e a ameaçaram de morte. O concurso

de agentes, somado ao emprego de arma de fogo, serviram como fatores determinantes para consumação do delito, eis que se prestaram a tornar real a ameaça empregada contra a vítima, retirando dela qualquer a capacidade de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa.

Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

"HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.

(...) 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)"

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Somadas as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, pois trata-se de concurso material de crimes, torno-a definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

Os condenados iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial, ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este, que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar CLAUDIO GABRIEL JESUS DOS SANTOS e ALEXANDRE DE LIMA MARQUES DA SILVA, a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa., como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 158, §§ 1º e 3º, e artigo, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA